

予備独自問題 H25-17

(配点: 3)

月 日

月 日

覚せい剤取締法違反被疑事件の捜査に関する次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、誤っているものの組合せは後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

【事 例】

路上で騒いでいる男がいるとの通報を受けた司法警察員Xらが、パトカーで現場に駆けつけたところ、甲が上半身裸で大声を出していた。Xらは、甲の言語や態度から、覚せい剤の使用を疑い、職務質問をすべく、パトカーから降りて甲に近づいた。甲は、Xらに気付くと、その場から立ち去ろうとしたため、①Xは、甲を追い掛け、「待ちなさい。」などと声を掛けながら、甲の肩に右手を掛けて引き留めた。甲は、ふて腐れた様子で文句を言ったが、それ以上、その場から離れようとはしなかったため、Xは甲の肩から手を離した。Xは、多くの野次馬が集まってきたため、甲に対し、最寄りのH警察署への同行を求めた。②甲は、当初、これを拒否していたが、最終的には渋々パトカーに乗りし、XらとともにH警察署に赴いた。同署に到着後、Xは、甲の左腕に注射痕らしきものがあるのを認め、甲に対し、覚せい剤使用の事実について尋ねたが、甲はこれを否定した。Xは、甲に対し、尿の提出を再三にわたって求めたが、甲はこれを拒絶し続けた。そこでXは、強制採尿もやむなしと考え、③裁判官より強制採尿令状の発付を受けた。Xは、甲に対し、同令状を示して再度尿の任意提出を求めたが、甲は、なおもこれを拒むとともに、最寄りのJ病院へ赴くことをも拒んだ。そこで④Xは、数名がかりで甲をJ病院まで連行した。甲は、同病院の病室に連行された後も、身体を動かして激しく抵抗し、説得にも応じなかったため、⑤Xら数名が甲の身体を同病室のベッド上に押さえた上で、医師において、カテーテルを甲の尿道に挿入して尿を採取した。同尿を鑑定したところ、覚せい剤の成分の含有が認められたことから、甲は、覚せい剤取締法違反（自己使用）の疑いで緊急逮捕された。

【記 述】

- ア. 下線部①については、職務質問において有形力の行使は一切許されないから違法となる。
 イ. 下線部②については、甲が最終的にパトカーに乗りすることには応じたとしても、その前後の状況によっては、甲をH警察署に連れて行った行為が違法と判断される場合がある。
 ウ. 下線部③の令状については、医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠である。
 エ. 下線部④については、甲を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合であっても、有形力を行使することは許されない。
 オ. 下線部⑤については、採尿を安全に実施するにつき必要最小限度にとどまるものと認められる有形力の行使は許される。

1. ア ウ 2. ア エ 3. イ エ 4. イ オ 5. ウ オ

No20	捜査における各種手続	正答率
予備H25-17	正解	93%
	2	

ア 誤っている

最決昭 29.7.15。本記述では、職務質問（警察官職務執行法2条1項、3項）における有形力の行使が一切許されないか問題となる。判例は、職務質問中に逃げ出した者を約30メートル追跡して背後から腕に手をかけ停止させた事案において、「距離の如何に拘らず停止を求めるためにその跡を追かけることは事物自然の要求する通常的手段方法であつて、客観的に妥当なものであると認むべくこれを目して強制又は強制的手段であるとは制底考へられないところであるし又同巡査が被告人の背後より『何うして逃げるのか』と言いながらその腕に手をかけたことも任意に停止をしない被告人を停止させるためにはこの程度の実力行為に出でることは真に止むを得ないことであつて正当な職務執行上の手段方法であると認むるを相当とする」とした原判決の判示を正当としており、一定の範囲内で有形力の行使を認めている。したがって、本記述では、有形力の行使は一切許されないとしている点で、誤っている。なお、任意捜査の限界について、判例（最決昭 51.3.16、百選1事件）は、「捜査において強制手段を用いることは、法律の根拠規定がある場合に限り許容されるものである。しかしながら、ここにいう強制手段とは、有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味するものであつて、右の程度に至らない有形力の行使は、任意捜査においても許容される場合があるといわなければならない。ただ、強制手段にあたらない有形力の行使であつても、何らかの法益を侵害し又は侵害するおそれがあるのであるから、状況のいかんを問わず常に許容されるものと解するのは相当でなく、必要性、緊急性などをも考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容されるものと解すべきである。」としている。

イ 正しい

最決昭 59.2.29（百選6事件）。本記述では、甲が任意に同行したとしても、その前後の状況によっては、甲を日警察署に連れて行った行為が違法と判断される場合があるか問題となる。判例は、任意同行及び任意同行後の取調べの適法性が問題となった事案において、「任意捜査の一環としての被疑者に対する取調べは、……強制手段によることができないというだけでなく、さらに、事案の性質、被疑者に対する容疑の程度、被疑者の態度等諸般の事情を勘案して、社会通念上相当と認められる方法ないし態様及び限度において、許容されるものと解すべきである。」とした上で、「これを本件についてみるに、まず、被告人に対する当初の任意同行については、捜査の進展状況からみて被告人に対する容疑が強まっており、事案の性質、重大性などにもかんがみると、その段階で直接被告人から事情を聴き弁解を徴する必要性があつたことは明らかであり、任意同行の手段・方法等の点において相当性を欠くところがあつたものとは認め難く、また、右任意同行に引き続くその後の被告人に対する取調べ自体については、その際に暴行、脅迫等被告人の供述の任意性に影響を及ぼすべき事跡があつたものとは認め難い。」としており、同行の状況によっては、違法と評価されることを認めている。よって、本記述でも、甲が最終的にパトカーに乗車することに応じたとしても、その前後の諸般の事情を勘案し、違法と判断される場合がある。したがって、本記述は正しい。

ウ 正しい

最決昭 55.10.23（百選28事件）。本記述では、搜索差押令状である強制採尿令状に、医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠かどうか問題となる。判例は、強制採尿が人権侵害のおそれのある点で検証としての身体検査と共通の性質を有するとして、身体検査令状に関する218条5項〔現218条6項〕を準用し、令状の記載要件とし

て、医師に医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の記載が不可欠であるとしている。したがって、本記述は正しい。

エ 誤っている

最決平6.9.16（百選29事件）。本記述では、甲を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合であっても、有形力を行使して連行することは許されないか問題となる。判例は、連行を認めないと強制採尿令状の目的を達することができないことや、このような場合に令状を発付する裁判官は、連行の当否を含めて審査しているとみられるということを理由に、強制採尿令状の効力として、採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができ、その際、必要最小限度の有形力を行使することができるとしている。したがって、本記述は有形力を行使することができないとしている点で、誤っている。

オ 正しい

最決昭55.10.23（百選28事件）。本記述では、採尿を安全に実施するにつき必要最小限度の有形力の行使は認められるかが問題となる。判例は、数人の警察官に身体を押さえつけられた状態で被告人の強制採尿を行った事案について、被告人が激しく抵抗していたことから、その身体を数人の警察官が押さえつけたとしても、その有形力は採尿の安全実施のために必要最小限度のものであり適法だとしている。したがって、本記述は正しい。

以上により、誤っている記述はアとエであり、したがって、正解は肢2となる。